

1500025-39.2022.8.26.0560

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... de atividade lícita remunerada também aponta para o tráfico.

Assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida no local, forma de armazenamento, bem como a nítida situação de tráfico demonstram o comércio espúrio. Os elementos de prova permitem responsabilizar o réu pelo tráfico, afastando-se a tese de fragilidade do conjunto probatório, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500025-39.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500025-39.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026213/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 22707289 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 459/22/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2026213 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2026213 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 459/22/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALEXANDRE BORGES MACENA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de MARCOS ALEXANDRE BORGES MACENA, vulgo "MK", pela prática, em tese, do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), e no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 ambos do Código Penal, consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 118/120): Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 21h30, na Travessa Bem-te-vi, altura do nº 2.121, Bairro Pró Povo,

nesta cidade e comarca, MARCOS ALEXANDRE BORGES MACENA, vulgo "MK", reincidente específico (fls. 52), qualificado a fls. 26/29, fotografado a fls. 41/44, portava dois cartuchos íntegros de calibre 38, e mantinha sob sua guarda outros três cartuchos íntegros, também de calibre 38, munições de uso permitido, conforme laudo pericial de fls. 104/107, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, MARCOS ALEXANDRE BORGES MACENA, já qualificado, trazia consigo quatro porções de maconha e 21 (vinte e uma) porções de crack, e guardava outras sete porções de maconha e 01 (um) tablete da mesma droga, tudo com o propósito de tráfico de drogas, com massa líquida total de 8,7g (crack) e 154,13g (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme fotografias de fls. 16/19, laudo de constatação provisória (fls. 21/23), e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.

A denúncia foi recebida no dia 28 de junho de 2022 (fls. 185/187).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na decisão de fls. 69/73, que autorizou a destruição da droga, reservada amostra a contraprova e acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido.

Citado (fls. 154) o acusado apresentou defesa prévia (fls. 175/177), por meio de defensora nomeada (fls. 162).

Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 185/187).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado. Seguiu-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Não há falar-se em nulidade da entrevista informal realizada pelos policiais militares no momento do flagrante pois não constitui interrogatório extrajudicial e, ademais, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.

A propósito: AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; e AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020.

Além disso, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na entrevista policial realizada por ocasião do flagrante e eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020).

De seu turno, quanto à busca domiciliar na residência sem mandado judicial ou prévia autorização, fica rejeitada, reconhecendo-se que as provas apreendidas a partir do ingresso policial na residência são consideradas lícitas, pois evidenciada a situação de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam.

Em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional (art. 5º, inciso XI, da Carta Magna) admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, em caso de flagrante delito, sendo certo que, consistindo o tráfico em infração de natureza permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado. A garantia constitucional não é absoluta.

Por fim, anoto que a matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para

afastamento dessa preliminar: “De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formado disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

No caso em tela, ademais, conforme depoimento dos policiais, a casa revistada estava abandonada, de modo que não havia a quem pedir permissão para a entrada. Havia, ainda, indícios suficientes do envolvimento do réu no tráfico, conforme detalhado no depoimento dos policiais.

De rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), nota de culpa (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), fotografias (fls. 16/19), laudo de constatação (fls. 21/23), laudo pericial (fls. 104/107 e 146/148), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127/129), laudo de exame pericial no celular apreendido (fls. 227/240) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127/129) constatou que as substâncias analisadas revelaram resultados POSITIVOS para COCAÍNA e ETRAHIDROCANNABINOL (THC), constantes na lista F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

O laudo pericial (fls. 104/107) constatou a eficácia e potencialidade lesiva dos artefatos apreendidos.

O laudo no celular do réu (fls. 227/240), com troca de mensagens relacionadas ao tráfico, demonstrando conversas relacionadas com fornecimento de droga e, ainda, consta armas e dinheiro nas fotos de fls. 237/239, inclusive o réu empunhando arma a fls. 238. A fls. 239 verifica-se anotações relacionadas ao tráfico.

A autoria, por seu turno, é certa e pode ser atribuída ao réu.

Com efeito, restou comprovado, diante dos depoimentos das testemunhas, desmerecendo por completo a negativa do réu. Vejamos.

Na fase inquisitiva, o policial militar Vladimir Sérgio de Freitas Júnior (fls. 03) disse que realizava patrulhamento com seu colega quando receberam uma denúncia de que o acusado estava traficando na Travessa Bem Te Vi e utilizando de uma casa abandonada para guardar as drogas. Chegando no local, observaram o acusado saindo do imóvel e, ao observar a presença dos policiais, empreendeu fuga, sendo detido. Em revista pessoal, encontraram 2 munições de calibre 38 íntegras, 04 porções de substância sugestiva para maconha embaladas individualmente envoltas em plástico preto, a quantia de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) distribuídas em notas diversas, 21 porções de substância aparentando ser crack dentro de um frasco plástico de cor verde e 01 telefone celular da marca “Xiaome”. Ao ser indagado sobre a origem, admitiu que vendia drogas. Quando adentraram a casa, localizaram, ainda, meio tablete de substância semelhante a maconha, outras 03 munições de calibre 38 íntegras e mais 07 porções individualmente embaladas em plástico preto de substância sugestiva para maconha. Não encontraram a arma de fogo. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Álvaro Martins de Oliveira (fls. 05). Em juízo, o sargento Vladimir confirmou a versão anterior. Disse que recebeu denúncias que o réu estava traficando para seu primo LK e, na data dos fatos, o avistaram saindo de uma casa abandonada, conseguiram detê-lo e, em seu poder, localizaram duas munições, porções de maconha, R\$ 148,00 e mais porções de crack em um plástico verde; sob uma pia foi localizado meio tablete de maconha, mais três munições e outras porções de maconha fracionadas. O primo do réu está envolvido em

homicídio, atualmente preso por preventiva. As denúncias mencionavam que o réu trabalhava para o primo e também mencionavam a casa abandonada. O réu, na ocasião, confessou que trabalhava para o primo, com quem tinha dívida. O réu correu da viatura, mas foi abordado.

Em juízo, o cabo Álvaro relatou que, dias antes, tinham recebido denúncia de que o réu, primo de LK, estaria pela cidade, usando uma casa na travessa Bem Te Vi para traficância e, adentrando na via, avistaram o réu, com as características mencionadas; em busca pessoal, localizaram droga, munições e dinheiro e, no imóvel, localizaram mais droga e munições, conforme descreveu em audiência. Quanto à droga, o réu admitiu a traficância, por conta de dívida com o primo LK.

Na fase inquisitiva, o réu (fls. 06/07) confessou o tráfico, afirmando que foi abordado por policiais, que encontraram em sua posse alguns entorpecentes, destinadas ao tráfico, não sabendo, contudo, o valor das drogas e nem sua origem. Negou o porte das munições calibre 38 no momento da abordagem. Não soube informar quem mora na casa em que foram encontradas as drogas. Disse que não autorizou as autoridades a acessar o conteúdo do seu celular. Por fim, disse que veio para a cidade para trabalhar, mas não deu certo e pegou drogas para vender.

Interrogado judicialmente, o réu negou a acusação; disse que é de Rio Preto. Pegou maconha para seu uso, na biqueira, o moleque entrou na casa e voltou com a droga; quando foi pagar o moleque, a polícia virou, os moleques correram e, como não devia nada para a justiça, parou; os policiais lhe bateram e, daí, saíram da casa com as munições e a maconha; reconhece apenas as quatro paradas de maconha para seu uso; não residia em Votuporanga, tinha vindo com seu tio João apenas para trabalhar; seu tio é construtor, estava trabalhando com ele. Não tem apelido, não é conhecido por MK. Já teve processo por tráfico, assumiu e pagou tudo. Não tem filhos. Acredita que os policiais tenham feito isso porque queriam que delatasse os moleques. Ficou trabalhando até umas nove e pouco, seu tio ficou até mais tarde para ganhar um extra; ele tinha ido comprar um lanche.

A prova colhida sob o crivo do contraditório desmerece a negativa do réu, fornecendo certeza de autoria. Ademais, percebe-se, claramente, que os depoimentos dos policiais são coesos e descrevem com pormenores a atuação do réu no tráfico de drogas e a apreensão das substâncias em sua posse e na casa usada como depósito, em consonância com os elementos colhidos.

Conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. Nesse sentido: "Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "jûris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagemas para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos." (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

Houve apreensão de diversidade de droga, uma parte em via pública e outra parte escondida na casa abandonada, que serviria a inúmeras porções. Foram, ainda, encontradas munições e o laudo no celular encontrado com o réu corrobora a traficância, bem como a potencialidade das munições, crime de perigo abstrato. Como tido, reforça a traficância o fato do acusado ter em depósito dois tipos diferentes de substâncias ilícitas, no caso, cocaína e maconha. Sendo o tráfico um negócio, à evidência, o agente criminoso sempre procura aumentar seu rol de consumidores expondo à venda a maior variedade possível de drogas, atendendo ao

gosto de cada usuário.

A posse de numerário (R\$ 148,00, em notas fracionadas) sem prova de desempenho de atividade lícita remunerada também aponta para o tráfico.

Assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida no local, forma de armazenamento, bem como a nítida situação de tráfico demonstram o comércio espúrio. Os elementos de prova permitem responsabilizar o réu pelo tráfico, afastando-se a tese de fragilidade do conjunto probatório, e ademais, razão alguma haveria para que os policiais incriminarem os réus de forma leviana.

Não há falar-se em desclassificação para uso, pois, ainda que o réu seja usuário, tal situação não é incompatível com a traficância.

Já em relação ao crime de porte ilegal de munições, sem determinação legal ou regulamentar, a negativa do réu foi desmerecida pelas provas colhidas, consoante laudo constatando a eficácia para disparos e depoimento dos policiais militares. Dessa forma, restou cabalmente comprovado que o acusado portava a arma sem a devida autorização, estando, portanto, consumado o delito.

Cuida-se de crime de perigo abstrato e se configura pelo mero porte não autorizado de munição, circunstância idônea, por si, a colocar em risco a incolumidade pública e a violar o bem jurídico protegido.

Desta forma, de rigor a condenação do réu pela prática dos crimes previstos na denúncia.

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena do réu.

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ e do art. 59 do Código Penal, fixo as penas-bases nos mínimos legais, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou seja, em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, para o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03. Observo que a quantidade e diversidade de drogas já integram o reconhecimento do tipo penal e da traficância, pelo que deixo de aumentar a pena por tais fundamentos.

Na segunda fase, o réu é reincidente (Processo nº 1500773-79.2019.8.26.0559), pelo que aumento a pena de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias-multa, e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Já na terceira fase, a reincidência obsta a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tornando definitiva a pena aplicada e, não havendo outras causas modificativas, torno definitivas as penas aplicadas.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador Constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007). O crime de porte de munições segue o mesmo regime.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu MARCOS ALEXANDRE BORGES MACENA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03 (reincidente). Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade (fls. 185).

O réu respondeu ao processo preso e persistem os requisitos da custódia cautelar, pelo que não poderá recorrer em liberdade, recomendando-se-o na prisão em que se encontra e, em caso de recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Autorizo, outrossim, a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para

contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Por fim, quanto ao numerário apreendido, decreto o perdimento em favor da União, providenciando-se oportunamente o encaminhamento e quanto ao celular, decreto o perdimento e, por conta do reduzido valor de mercado, autorizo a destruição, comunicando-se a Autoridade Policial responsável.

Expeça-se certidão de honorários à Patrona nomeada, por força do convênio OAB/DPE. Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) expedição de guia definitiva para o cumprimento da pena; (ii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iii) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (iv) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cumpra-se.

Votuporanga, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA